

0009077-95.2021.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Fernanda Franco Bueno Cáceres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... em hipóteses de furto ou roubo do cartão. Recurso improvido" (TJ/SP - Recurso Inominado 0005574-90.2017.8.26.0007 - 1ª Turma Recursal Cível e Criminal - Rel. Paulo Roberto Fadigas César - j. 20.10.17).

Nesse sentido também os seguintes julgados: Recurso Inominado 0319952-

68.2009.8.26.0100 - Colégio Recursal Central da Capital - 1ª Turma - Rel.

Alessandra Laskowski - j. 23.02.11; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

Juizado Especial Cível Anexo UNIP

Rua Cancioneiro de Évora, 490,, São Paulo-SP - cep 04708-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009077-95.2021.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009077-95.2021.8.26.0002

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Maria Lucia Carvalho dos Santos

Requerido:

Itaú Unibanco S/A

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Franco Bueno Cáceres

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por primeiro, não há que se falar em extinção do processo sem análise do mérito pela inércia da parte autora, que apenas não se manifestou a respeito de interesse na produção do provas. Sua inércia especificamente causa apenas a preclusão da prova, nada mais.

De se rechaçar por completo a preliminar de incompetência deste juízo para análise e julgamento da demanda, tendo em vista que, para deslinde do ponto controvertido, não há que se reconhecer a necessidade de realização de perícia de alta complexidade. Acrescente-se ainda que seria possível a realização de perícia de menor complexidade no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento consagrado há tempos no Enunciado 7 dos Encontros do Colégio Recursal Central da Capital (neste sentido: CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e prática dos Juizados Especiais Cíveis estaduais e federais. 7 ed. atual. e rev. São Paulo: Ed. Saraiva, 2004, p. 61).

A jurisprudência do Colégio Recursal vem entendendo pela inutilidade de tal prova

em casos como o dos autos:

"PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROVA PERICIAL. Arguida a necessidade de prova técnica e sendo os elementos constantes dos autos suficientes para o julgamento da lide, revela-se desnecessária a produção de prova pericial. Afastamento da preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Alegação de ocorrência de assalto na porta da residência do pai da autora, já na via pública. Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo em hipóteses de furto ou roubo do cartão. Recurso improvido" (TJ/SP - Recurso Inominado 0005574-90.2017.8.26.0007 - 1ª Turma Recursal Cível e Criminal - Rel. Paulo Roberto Fadigas César - j. 20.10.17).

Nesse sentido também os seguintes julgados: Recurso Inominado 0319952-68.2009.8.26.0100 - Colégio Recursal Central da Capital - 1ª Turma - Rel. Alessandra Laskowski - j. 23.02.11; Recurso Inominado 00151-43.201.8.26.902 - Colégio Recursal Central da Capital - 3ª Turma - Rel. Alberto Gibin Villela - j. 04.03.11.

Rechaço também a preliminar de falta de interesse processual da parte requerente por não ter buscado atendimento na via administrativa. Ainda que não haja provas de que a autora tenha contatado o gerente de sua agência, tal como alegado na inicial, certo é que a consumidora apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à jurisdição, garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Outrossim, a parte requerida resiste à pretensão inicial, demonstrando, pois, necessidade e adequação da presente demanda.

A designação de audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 da Lei 9.099/95), sem possibilidade de dispensa, é característica intrínseca à essência dos Juizados Especiais. Por outro lado, a situação excepcional vivida por todo o mundo no presente momento, causada pela pandemia de Covid-19, acabou por impor a adaptação da atividade jurisdicional, com alternância de momentos de trabalho integralmente remoto e outros na forma híbrida, enquanto subsistir a excepcionalidade. Tão essenciais quanto a obrigatoriedade da audiência de conciliação são o princípio da celeridade processual, característico do procedimento regido pela Lei 9.099/95 (artigo 2º), e aquele constitucional da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Por isso mesmo, e levando em consideração a anuência das partes, oportuno e conveniente que a audiência de conciliação seja dispensada no caso concreto.

Também, analisando os autos após o prazo de oferecimento de réplica, de se reconhecer a desnecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, o que, nos termos do Enunciado nº 16 do Comunicado nº 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais (DJE 07/12/2010), não trará qualquer nulidade na forma do artigo 13 da Lei nº 9.099/95. Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de dilação probatória (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil), em especial da tomada do depoimento pessoal da autora, tal como vem entendendo a jurisprudência em casos similares:

"APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA Preliminar suscitada pelo réu de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa Rejeição Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado da lide Desnecessidade da prova requerida (depoimento pessoal da autora) PRELIMINAR REJEITADA" (TJ/SP - Apelação 1002694-82.2016.8.26.0609 - 13ª Câmara de Direito Privado - Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca - j. 18.04.18).

"AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE - DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA - INVERSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90 - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE - NOME - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8º DO CPC - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO RÉU NÃO provido" (TJ/SP - Apelação 0001751-28.2015.8.26.0315 - 11ª Câmara de Direito Privado - Rel. Tavares de Almeida - j. 16.11.17).

Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

No mérito, o pedido inicial merece acolhimento em parte.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais sofridos em razão de um saque realizado na conta da autora, no montante total de R\$ 1.000,00, por dois indivíduos que a coagiram. A autora alega que foi vítima de um crime patrimonial no dia 11 de março de 2019, conforme boletim de ocorrência de fls. 05/06.

Tal como narrado, após efetuar um saque em caixa eletrônico situado dentro de um hipermercado, a autora foi abordada por um indivíduo, informando que a "tela" ainda estava aberta. A autora não levou em consideração e continuou seu caminho, mas outro indivíduo insistiu e ela retornou ao caixa. Lá, os dois meliantes a coagiram, ameaçando-a para que digitasse sua senha, segurando sua mão para que fossem colhidas suas digitais. Referido relato foi apresentado tanto em sede policial quanto em juízo.

O banco impugna tal versão, alegando, em qualquer fundamento, que a autora teria sido vítima do golpe da troca do cartão. O fato de a autoridade policial ter qualificado a ocorrência como "furto qualificado", mesmo diante da narrativa apresentada, não é suficiente para afastar a caracterização do ilícito tal como narrado pela vítima, mesmo porque a qualificação da autoridade policial não vincula nem o titular da ação penal nem o Juízo.

De todo modo, seja o caso de roubo seja o caso de fraude, como se passará a expor, no caso concreto, o banco-requerido responde perante o consumidor.

Não há dúvida quanto à aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), em especial a responsabilidade objetiva, bem como da Teoria do Risco da Atividade no que se refere às instituições bancárias. O banco ainda, apesar de alegar de forma genérica, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, não prova qualquer das excludentes de responsabilidade.

Não lhe socorre a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Não se está aqui a responsabilizar a instituição bancária pelo ato dos criminosos, mas sim pela falha no seu sistema de segurança nas operações com cartões bancários. Cumpria ao banco garantir a disponibilidade de dispositivos que dariam mais segurança às operações, como, por exemplo, sistema de registro de imagens nos terminais eletrônicos, exigência de informações adicionais e aleatórias de identificação do cliente, que não apenas a digitação da senha, adequado e constante controle de oscilações no perfil do titular do cartão, dentre outros.

Com fundamento nesta realidade foi editada a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias". Neste sentido já se decidiu que:

"Apelação Cível. Contratos bancários. Cliente vítima de sequestro relâmpago.

Subtração de cartão de crédito. Compra realizada pelos criminosos e posteriormente cobrada do usuário. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco. Teoria do Risco do Negócio. Dever de segurança do serviço. Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Falhas no serviço bancário demonstradas. Atipicidade do alto valor da compra, destoando do habitual padrão de consumo do cliente. Anomalia não identificada nem reprimida pelo banco. Ocorrência, demais, imediatamente comunicada à instituição, com o bloqueio do cartão. Omissão da instituição financeira em não cancelar, tempestivamente, a compra junto ao lojista. Valor corretamente declarado inexigível. Danos morais, porém, não configurados. Transtornos que, embora inegáveis, não geram afetação a direitos personalíssimos. Sucumbência recíproca reconhecida. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido" (Apelação 1062529-44.2014.8.26.0100 - Relator(a): Hélio Nogueira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/04/2016; Data de registro: 02/05/2016).

Apesar de o banco ter alegado que a operação impugnada não fugiu do perfil de

consumo da autora, certo é que não comprovou a semelhança do saque de R\$ 1.000,00, realizado simultaneamente após um saque de R\$ 500,00, com outros saques que a autora já realizou. Aliás, a própria contestação do banco demonstra a falha no seu sistema de segurança, na medida em que reconhece ter recusado a aprovação de um segundo saque no valor de R\$ 1.000,00. Ora, por que não o fez já no primeiro saque? O extrato de conta corrente demonstra que para a realização do primeiro saque foi utilizado todo o limite de R\$ 300,00 da conta da autora, superando-o (saldo devedor de R\$ 328,99 (fls. 07)). Errou duas vezes o banco, portanto: seja por não ter constatado a divergência com o perfil de consumo, seja por não ter reconhecido a fraude em um saque simultâneo em valor jamais sacado pela autora, seja porque desde o primeiro saque o valor excedia o limite LIS concedido à autora.

A simples constatação de que as operações foram realizadas com o uso de cartão com chip e senha pessoal não afasta a ocorrência de falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

"AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - relação de consumo - responsabilidade objetiva - artigo 14 do CDC - apelado vítima de sequestro relâmpago - transações impugnadas que discrepavam do perfil da titular do cartão - operações sequenciais, mediante o uso de mesma maquineta, realizadas de madrugada, durante o período da pandemia da Covid-19 - bloqueio preventivo do cartão que deveria ter sido providenciado - falha na prestação de serviços - declaração de inexigibilidade das operações e determinação de devolução de valores que se impunha - existência de nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano material - sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP - apelante que pediu alternativamente que a indenização por dano moral fosse reduzida - inexistência de pedido de reparação pertinente a essa espécie de dano - recurso não conhecido quanto ao tópico. Resultado: recurso desprovido quanto à parte conhecida". (TJSP; Apelação Cível 1004746-18.2020.8.26.0704; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2021; Data de Registro: 06/12/2021).

"APELAÇÃO. Ação de declaratória e indenizatória por danos materiais e morais em razão de compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito do autor que foi vítima de sequestro relâmpago. Sentença de parcial procedência, para condenar o banco réu a restituir os valores cobrados indevidamente. Sucumbência recíproca decretada. Apelo da financeira pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Consumidor que foi vítima de sequestro relâmpago. Cartão bancário utilizado por criminosos. Transações que caracterizam uso fora dos padrões. Inexistência de culpa exclusiva do consumidor. Instituição financeira que apresentou falha em sua segurança, não cabendo ao cliente arcar com os prejuízos. Danos materiais caracterizados. Manutenção do decidido. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1001393-71.2020.8.26.0153; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2021; Data de Registro: 22/11/2021).

Por fim, o fato de o crime ter ocorrido fora do estabelecimento do requerido não afasta sua obrigação de segurança no sistema que operacionaliza as operações bancárias. O banco não fez qualquer impugnação específica quanto aos valores apresentados na inicial. Assim, presumem-se verdadeiros.

Os danos morais também devem ser verificados na medida em que o banco-requerido falhou no seu dever de cuidado com patrimônio do consumidor, frustrando sua expectativa de segurança nas transações financeiras. Em caso similar assim e decidiu:

"INDENIZAÇÃO - SEQUESTRO RELÂMPAGO SOFRIDO FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA - TRANSAÇÕES QUE FOGEM INTEIRAMENTE AO PERFIL DO CORRENTISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CONSIDERADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - AÇÃO PROCEDENTE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA". (TJSP; Apelação Cível 1014043-69.2021.8.26.0007; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021).

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que o requerido-fornecedor corrija seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar dano ou sua propagação ao consumidor. Neste sentido: "O valor da reparação dos danos deve ser suficiente para que se restabeleça o equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em retribuição, na concepção aristotélica de Justiça. O valor também deve apresentar-se em consonância com os objetivos da indenização por danos morais, quais sejam, a reparação do sofrimento, do dano causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao ofensor para que não volte a incidir na mesma falta. Portanto, a estimativa do dano moral deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta do réu e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as partes" (TJ/SP - Apelação 1028030-43.2015.8.26.0506 - 23ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. FRANCO DE GODOI - J. 05.04.2017).

Conforme o entendimento do E. STJ, "a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta" (REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do STJ, 18/41, 2ª quinzena de novembro de 2001).

Destarte, consideradas as circunstâncias do caso concreto, entendo de todo desarrazoado o valor pretendido pela parte requerente (R\$ 3.000,00) e, por isso, fixo a indenização no valor de R\$ 1.000,00, quantia que reputo razoável e suficiente para a reparação do abalo moral sofrido por ela e para reprimir a prática de novos atos semelhantes pela ré, sem significar enriquecimento ilícito daquela.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar o réu a: a) restituir à autora a quantia de R\$ 1.000,00, atualizada pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data do saque indevido (março de 2019) e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) pagar à autora a quantia de R\$ 1.000,00, a título de danos morais, atualizada pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde esta sentença e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem sucumbência por força do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), nos termos do Comunicado CG 1530/2021. Cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, a seguir:

<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>, sob pena de deserção de eventual recurso. O recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade para retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, a Serventia procederá à inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria. Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se as partes.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se as partes.

Nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos, com as cautelas de

praxe.

Dispensado o registro da sentença, nos termos do artigo 72, parágrafo 6º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, publique-se e intime-se.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA